

1500488-81.2022.8.26.0559

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAROLINA CASTRO ANDRADE SILVA

Comarca: José Bonifácio

Foro: Foro de José Bonifácio

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 05/07/2022

... confissão, corroboram a existência do tráfico.

Cabe observar que é lícito o ingresso em domicílio mediante autorização do morador ou, mesmo sem mandado judicial, se houver fundados indícios da existência de flagrante delito (art. 5º, XI, da Constituição e art. 240 do CPP). Como o tráfico, na modalidade de guardar ou ter em depósito drogas, é crime permanente, sua consumação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de José Bonifácio

Foro de José Bonifácio

1ª Vara

Av. Monsenhor Ângelo Angioni, nº 1000, José Bonifácio-SP - cep 15200-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500488-81.2022.8.26.0559 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500488-81.2022.8.26.0559

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu

ENILDO OLIVEIRA DOS ANJOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAROLINA CASTRO ANDRADE

ENILDO OLIVEIRA DOS ANJOS (fls. 30) foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 (fls. 83/86).

Isso porque, segundo consta, em 15 de março de 2022, às 21h30min, na Rua Wester Rodrigo Dezan, n.º 40, nesta cidade e comarca de José Bonifácio-SP, o acusado praticou o ato de trazer consigo, ter em depósito e guardar, para entrega a consumo de terceiros, 01 tijolo do entorpecente conhecido por maconha, bem como 22 porções de maconha, pesando ao todo 647,33 gramas; 1 trouxa contendo o entorpecente cocaína na forma de crack, pesando 12,76 grama e, 05 porções de cocaína, pesando 2,41 gramas e, ainda, uma balança de precisão, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Foi apresentado o seguinte rol de testemunhas: PM Denise da Silva Francisco (fls. 3/4), PM Vinícius Othávio Piccoli Zanchin (fls. 5) e Adeir Luis da Cruz Pereira (fl. 6).

Foi decretada a prisão preventiva do acusado (fls. 59/61).

Recebida a denúncia (fls. 88), o acusado foi citado pessoalmente (fls. 145) e apresentou defesa prévia (fls. 158/160), por defensora nomeada (fls. 149), negando a prática do delito e pedindo absolvição, sem arrolar testemunhas.

O recebimento da denúncia foi ratificado (fls. 172), sendo realizada audiência de

instrução.

As partes apresentaram alegações finais orais. O Ministério Público pediu a condenação nos termos da denúncia, enquanto a Defesa pediu absolvição por falta de provas.

É o relatório.

Decido.

A autoria e materialidade dos fatos restaram indiciariamente demonstradas pelo boletim de ocorrência (fls. 9/13), termos de declarações, depoimentos e interrogatório (fls. 3/7), auto de apreensão e entrega (fls. 14/15), auto de arrecadação (fl. 16), laudo de constatação (fl. 18/21), fotografias (fls. 36/39), laudos periciais (fls. 97/116 e fls. 183/185) e relatório final (fl.118/120).

Por sua vez, o contexto probatório produzido sob o crivo do contraditório dá respaldo à acusação.

Conforme a denúncia:

Segundo se apurou, em circunstâncias que serão melhor aclaradas na instrução criminal, o denunciado obteve a substância ilícita acima mencionada e passou a mantê-la em depósito, com o fim de comercializá-la.

Na data dos fatos, os policiais militares em patrulhamento pela cidade avistaram o denunciado defronte o imóvel, local dos fatos, conversando com terceiro não identificado. Ao avistar a aproximação dos policiais ENILDO OLIVEIRA DOS ANJOS, em atitude suspeita, jogou 05 invólucros contendo a droga conhecida por maconha, embaladas e prontas para a venda e, tentou adentrar a sua residência, porém, foi abordado defronte o imóvel.

Indagado o denunciado assumiu a propriedade dos entorpecentes, relatou que, pelo fato de não conseguir emprego estava vendendo drogas. Informando a existência de outras drogas no interior do imóvel.

Em vistoria realizada no interior da residência do denunciado os policiais localizaram e apreenderam dentro de uma geladeira em funcionamento, um tijolo de maconha e 17 porções menores de maconha, embaladas e prontas para a venda e, sobre a referida geladeira, localizaram e apreenderam uma balança de precisão. Ainda, dentro de outro refrigerador, desligado, localizaram e apreenderam 1 trouxa de "crack" e embalagens vazias.

Outras 05 porções de cocaína; um simulacro de arma de fogo e R\$.360,00 em notas diversas e R\$.52,85 em moedas diversas, além de um saquinho contendo sementes de maconha, foram apreendidos dentro de uma gaveta da cômoda localizada no quarto do denunciado. Laudo de exibição e apreensão acostado às fls. 14/15.

O material apreendido foi submetido a perícia que constatou, no 01 tijolo do entorpecente conhecido por maconha, bem como nas 22 porções de maconha, pesando ao todo 647,33 gramas, a presença da substância Tetrahydrocannabinol (THC), que se encontra descrita na lista F2 (Lista das substâncias Psicótropicas) da Lista F (Lista das Substâncias de Uso Proscrito no Brasil) da Portaria ANVISA 344/1998 e atualizações posteriores. Ainda, na trouxa contendo o entorpecente cocaína na forma de crack, pesando 12,76 grama e, nas 05 porções de cocaína, pesando 2,41 gramas, foi constatada a presença de cocaína, droga proibida, constante na lista F1 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020). Laudos de constatação de drogas acostado às fls. 18/21.

A quantidade, o modo de acondicionamento da droga apreendida, bem assim as circunstâncias da prisão, revelam o inequívoco intuito de tráfico de drogas.

Foram apreendidos: uma corrente de pescoço dourada com riscos; uma carteira marrom; duas embalagens com diversos sacos de dois tamanhos; um celular com capa, na cor azul/verde, com diversos riscos; uma arma de fogo com simulacro similar a pistola luger com cabo dourado; uma balança de precisão prata; cédulas e moedas de diversos valores totalizando o valor de R\$ 412,85; 03 pés de maconha acondicionados em 2 vasos; 6,52 gramas de semente de maconha; uma pedra de crack de 19,26 gramas; 5 papелotes com 9,03 gramas de cocaína e 23 porções com 649,2 gramas de maconha.

O laudo de constatação apontou resultado positivo para:

1- cocaína nas amostras colhidas de invólucro plástico fechado por pressão encerrando porção de material sólido petrificado com massa líquida de 12,76 grama(s);

2- cocaína nas amostras colhidas de cinco invólucros plásticos fechados por pressão encerrando porção de material sólido particulado com massa líquida de 2,41 grama(s);

3-tetrahydrocannabinol - THC nas amostras colhidas de vinte e três invólucros plásticos, sendo 01 invólucro constituído por fita adesiva retorcida encerrando porção de fragmentos vegetais ressequidos, constituídos de folhas, folíolos, inflorescências, caules e frutos, compactadas na forma de tijolo; 17 invólucros plásticos fechados por pressão e 05 invólucros plásticos fechados por aquecimento encerrando porção de fragmentos vegetais ressequidos, constituídos de folhas, folíolos, inflorescências, caules e frutos, com massa líquida de 647,33 grama (s). O laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 97/99) apontou resultado positivo para:

1- cocaína nas amostras colhidas de invólucro plástico encerrando porção de material sólido petrificado com massa líquida de 2 grama(s);

2- cocaína nas amostras colhidas de invólucros plásticos encerrando porção de material sólido particulado com massa líquida de 2 grama(s);

3-tetrahydrocannabinol - THC nas amostras colhidas invólucros plásticos, encerrando porção de fragmentos vegetais ressequidos, constituídos de folhas, folíolos, inflorescências, caules e frutos, com massa líquida de 2 grama(s).

O laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 100/102) apontou resultado positivo para: tetrahydrocannabinol - THC nas amostras colhidas de invólucro plástico lacrado encerrando, 02 vasos contendo terra e plantas arbustivas constituídas por raiz, caule, folhas, folíolos, inflorescências, caules e frutos, sendo um vaso de cor preta, com dimensões aproximadas de 10 cm x 9cm x 9 cm, contendo 2 plantas arbustivas, uma com cerca de 50 cm de comprimento, e outra com cerca de 18 cm de comprimento (item A, massa líquida: 1,17g); e um vaso confeccionado com fundo de garrafa tipo PET transparente, com dimensões aproximadas de 14 cm de altura x 10 cm de diâmetro, contendo 1 planta arbustiva com cerca de 40 cm de comprimento (item B, massa líquida 0,51 g).

O laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 103/105) apontou resultado positivo para: cocaína e tetrahydrocannabinol - THC nas amostras colhidas de invólucro plástico lacrado encerrando, 1 balança digital de metal cinza (coloração prateada), usada, sem marca aparente, medindo 12 cm de comprimento e 6 cm de largura. Na parte frontal da balança há 5 botões com as seguintes inscrições: ON/OFF (liga e desliga), UNITS (unidade), TARE (tara), LIGHT (Luz) e PCS, e uma tampa frontal transparente. A balança possui na parte traseira compartimento de encaixe das pilhas e as inscrições 500g/0.1g QC PASS. A peça opera/funciona com uso de 2 pilhas alcalinas do tipo AAA, as quais estavam presente. A balança apresentava resquícios/sujidades e quando da realização do exame pericial, encontrava-se funcionando normalmente. Ressalta-se que é comum o uso deste tipo de objeto (balanças manuais) na pesagem de substâncias entorpecentes.

O laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 110/112) apontou resultado positivo para: tetrahydrocannabinol - THC nas amostras colhidas de 01 invólucro plástico fechado por pressão encerrando porção de material com aspecto de origem vegetal, de formato esférico, coloração amarronzada e com diâmetro médio de aproximadamente 3,0 mm, dotada de resquícios de fragmentos vegetais ressequidos, com massa líquida de 0,64 g).

O laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 113/115) apontou resultado positivo para: tetrahydrocannabinol - THC nas amostras colhidas de invólucro plástico encerrando 2 pacotes de embalagens plásticas, com as inscrições " Sacos Zip 00 e Sacos Zip 01 contém 100 unidades", cada unidade dotada de dimensões aproximadas de 4 cm x 4 cm e 5 cm x 7 cm, respectivamente, da marca Grespan. As embalagens zip somaram cerca de 45 unidades na medida 4 cm x 4 cm e 81 unidades na medida 5 cm x 7 cm, todas apresentando resquícios/sujidades, com massa líquida de 50 g). Ressalta que é comum o uso deste tipo de objeto (sacos plásticos do tipo Zip) na embalagem e fracionamento de substância entorpecente.

O laudo pericial (fls. 183/185) analisou uma réplica de arma de fogo do tipo pistola, usada, sem marca, modelo ou numeração de série aparentes, semelhante ao modelo real Luger, fabricado pela antiga fábrica alemã Deutsche Waffen-und

Munitionsfabriken, com estrutura, cano e mecanismo de ação metálica e também confeccionada com polímero, de cor preta e cabo lateralmente castanho. Apresenta mecanismo para arremessar projéteis esféricos mediante pressão, com acionamento por mola (spring) e carregador ('magazine'), este presente. A réplica é do calibre 5 mm e revelou-se eficaz para disparar projéteis na maneira para a qual foi fabricada. A testemunha PM Denise da Silva Francisco narrou que, durante o patrulhamento, adentraram uma rua sem saída e avistaram um indivíduo na calçada. Esse indivíduo já saiu e o morador tentou entrar na residência, mas deixou cair umas porções de maconha. Ao avistar a viatura, o acusado dispensou a droga na frente da residência, entre o portão e a parte interna da casa. Ali mesmo o acusado foi abordado. Ele estava traficando por estar desempregado e convidou os policiais a entrar. Ele apontou onde estavam as porções de maconha, sementes e simulacro. As drogas estavam em uma geladeira ligada e outra em uma geladeira desligada. Em cima de uma das geladeiras estava a balança. Na cômoda do quarto dele havia cocaína, simulacro, sementes e dinheiro. As porções estavam no fundo da gaveta. No quarto havia dois pés de maconha. Já o conhecia dos meios policiais por brigas de casal e coisas corriqueiras. A depoente não abordou o acusado por fato relacionado a tráfico. A testemunha PM Vinícius Othávio Piccoli Zanchin afirmou que, em patrulhamento pelo bairro, avistaram duas pessoas e um saiu fora. Em busca pessoal do acusado, no chão foram localizadas 5 porções de maconha. O acusado afirmou que a droga era sua. Indagado, afirmou que havia mais drogas na residência e franqueou a entrada. Ali estavam mais entorpecente, simulacro de arma de fogo e valores em dinheiro. O acusado afirmou que estava traficando há cerca de 6 meses e estava desempregado. Na ocasião um amigo dele estava morando com ele e foi conduzido como testemunha; ele falou que sabia do tráfico.

Houve desistência da testemunha Adeir Luis da Cruz Pereira.

Em seu interrogatório, o acusado confessou a acusação, afirmando que estava desempregado e pediu dinheiro emprestado para um rapaz, gesseiro; como forma de pagamento, o interrogando aceitou receber a droga que seria vendida. A viatura chegou na sua casa e franqueou a entrada porque não teve opção e sentiu medo de apanhar.

Diante das narrativas oferecidas, concluo que o delito está efetivamente caracterizado, essencialmente, pelos fundamentos abaixo.

Em patrulhamento, um indivíduo e o acusado foram vistos na calçada de uma rua sem saída; ao avistarem a viatura, o indivíduo se evadiu e o acusado dispensou drogas entre o portão e a parte interna da casa e tentou adentrá-la, sendo abordado. O acusado admitiu que estava na posse da drogas, em razão de dificuldades financeiras, e apontou onde elas estavam guardadas. Também foram apreendidos balança de precisão, simulacro de arma de fogo, dinheiro e sementes.

Pela quantidade, variedade e modo de acondicionamento das drogas e pelos locais onde foram encontradas, não é possível afirmar de plano que elas se destinavam a consumo pessoal (art. 28, §2º, da Lei 11.343/06).

Além disso, a apreensão de petrechos e quantia em dinheiro, somadas à confissão, corroboram a existência do tráfico.

Cabe observar que é lícito o ingresso em domicílio mediante autorização do morador ou, mesmo sem mandado judicial, se houver fundados indícios da existência de flagrante delito (art. 5º, XI, da Constituição e art. 240 do CPP). Como o tráfico, na modalidade de guardar ou ter em depósito drogas, é crime permanente, sua consumação se prolonga no tempo, de modo que o agente se encontrará em flagrante delito enquanto não cessar a permanência (art. 303 do CPC).

No caso, o acusado foi visto dispensando a droga na frente da residência onde morava, o que caracterizou situação de flagrante a legitimar a busca domiciliar. Ademais, o acusado não relatou ter sido coagido para falar onde as drogas se encontravam, nem há indícios mínimos de que ela sofreria represália, por ele imaginada, caso se mantivesse em silêncio. Diante disso, não houve ilicitude ou abuso apto a acarretar a ilicitude das provas obtidas:

1. Durante a realização de diligência verificar a existência de indícios de crime após o recebimento de notícia anônima circunstanciada, a guarnição policial se deslocou até o local dos fatos. O agravante, por sua vez, ao avistar a viatura

policial empreendeu fuga, no que foi seguido pelos policiais até que adentrou à residência. Diante da fundada suspeita da prática de crime, os milicianos adentraram à residência e lograram apreender significativa quantidade de entorpecente.

2. "Tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de drogas, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida" (RHC 99.309/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 10/8/2018). (AgRg no HC 556.588/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020)

II - Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência" (AgRg no REsp n. 1.637.287/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 10/05/2017).

III - A garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente. Precedentes.

IV - No caso dos autos, a entrada dos policiais não decorreu de mera "atitude suspeita" dos pacientes, porquanto, conforme consignado pelo eg. Tribunal a quo, os milicianos "realizavam patrulhamento de rotina" quando "os dois adolescentes, ao verem a viatura policial, correram para dentro do lote" e "diante da atitude suspeita, entraram no lote" (fl. 278), eventos por si só suficientes para configurar as "fundadas razões" para se concluir que havia flagrante delito em andamento, bem como a autorizar o ingresso em domicílio sem autorização judicial ou consentimento. Não obstante, soma-se a essa circunstância o fato de ter havido autorização para o ingresso na residência, visto que "a irmã de um dos adolescentes autorizou a entrada dos policiais na casa" (fl. 280). Habeas corpus não conhecido. (HC 540.714/DF, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

Vale dizer ainda que o simples fato de as testemunhas serem policiais, por si só, não tem o condão de enfraquecer seus depoimentos, os quais devem ser valorados com isenção e em cotejo com os demais elementos probatórios:

Segundo entendimento reiterado desta Corte, as declarações dos policiais militares responsáveis pela efetivação da prisão em flagrante constituem meio válido de prova para condenação, sobretudo quando colhidas no âmbito do devido processo legal e sob o crivo do contraditório. (...) (HC 395.325/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017)

O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova. (AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016)

Sequer há motivo para se imaginar que os agentes ou terceiras pessoas desconhecidas pretendessem incriminar o acusado falsamente, mesmo porque os policiais não o conheciam de abordagens anteriores.

Por sua vez, a Defesa não conseguiu demonstrar a falibilidade dos depoimentos das testemunhas. Com efeito, não basta apenas argumentar que inexistente presunção de veracidade dos depoimentos dos policiais ou que não é possível presumir a culpa apenas porque a droga foi encontrada dentro do imóvel. É preciso ir além das teses, oferecendo-se explicação concreta para os fatos. A versão apresentada pelo acusado precisaria ser verossímil e não foi. Na verdade, a tese de Defesa pressupõe que a conduta dos agentes assumiu conotação abusiva ou que alguém desconhecido queria prejudicá-lo, mas não há razão concreta e idônea que a sustente, pelos motivos já expostos.

Ressalte-se também que nada impede que a traficância ocorra em paralelo com o uso de drogas e/ou com o exercício de ocupação lícita, razão pela qual tais alegações não afastam a caracterização da conduta típica. Ademais, o art. 33, caput, da Lei 11.343/06 se caracteriza como tipo misto alternativo, de maneira que basta que o

agente incorra em qualquer das condutas ali mencionadas, dentre elas a de ter drogas em depósito, sem autorização, como descrito na denúncia. Logo, a conduta não está acobertada por causa excludente de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade, restando bem caracterizada a prática do delito. Por tais motivos, a pretensão punitiva procede.

Passo à dosimetria.

Nessa tarefa, cabe observar o critério trifásico (art. 68 do CP) e os princípios constitucionais da proporcionalidade e individualização das penas (art. 5º, XLVI, da Constituição).

Nesse sentido, o Código Penal prevê que o patamar da pena deve ser “necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime” (art. 59, caput).

Ademais, no tocante especificamente aos crimes previstos na Lei 11.343/06, vale lembrar que “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente” (art. 42).

Prevalece na jurisprudência que, por serem circunstâncias preponderantes e devido à vedação ao bis in idem, a natureza e a quantidade de entorpecente devem ser valoradas apenas na primeira fase da dosimetria e só podem ser usadas na terceira fase para afastar o tráfico privilegiado se estiverem conjugadas com outras circunstâncias do caso concreto, que, unidas, caracterizem a dedicação do agente a atividades criminosas ou integração a organização criminosa:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE. NECESSIDADE DE INCIDÊNCIA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006). PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS EVIDENCIADORES DA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA OU DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador.

2. O tratamento legal conferido ao crime de tráfico de drogas traz peculiaridades a serem observadas nas condenações respectivas; a natureza desse crime de perigo abstrato, que tutela o bem jurídico saúde pública, fez com que o legislador elegeisse dois elementos específicos – necessariamente presentes no quadro jurídico-probatório que cerca aquela prática delituosa, a saber, a natureza e a quantidade das drogas – para utilização obrigatória na primeira fase da dosimetria.

3. O tráfico privilegiado é instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual.

4. No julgamento do RE n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral (Tese n. 712), o STF fixou o entendimento de que a natureza e a quantidade de entorpecentes não podem ser utilizadas em duas fases da dosimetria da pena.

5. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do REsp n. n. 1.887.511/SP (DJe de 1º/7/2021), partindo da premissa fixada na Tese n. 712 do STF, uniformizou o entendimento de que a natureza e a quantidade de entorpecentes devem ser necessariamente valoradas na primeira etapa da dosimetria, para modulação da pena-base.

6. Não há margem, na redação do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, para utilização de suposta discricionariedade judicial que redunde na transferência da análise dos vetores “natureza e quantidade de drogas apreendidas” para etapas posteriores, já que erigidos ao status de circunstâncias judiciais preponderantes, sem natureza residual.

7. A natureza e quantidade das drogas apreendidas podem ser utilizadas, supletivamente, na terceira fase da dosimetria da pena, para afastamento da diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2016, apenas quando esse vetor for conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas,

caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa.

8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 687.767/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021)

PENAL, PROCESSO PENAL E CONSTITUCIONAL. DOSIMETRIA DE PENA. PECULIARIDADES DO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE A SER OBSERVADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO OU MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO TOLERÂNCIA NA ORDEM CONSTITUCIONAL. RECURSO PROVIDO PARA RESTAURAÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.

1. A dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador.

2. Em regra, abre-se espaço, em sua primeira fase, à atuação da discricionariedade ampla do julgador para identificação dos mais variados aspectos que cercam a prática delituosa; os elementos negativos devem ser identificados e calibrados, provocando a elevação da pena mínima dentro do intervalo legal, com motivação a ser necessariamente guiada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. Na estrutura delineada pelo legislador, somente são utilizados para a fixação da pena-base elementos pertencentes a seus vetores genéricos que não tenham sido previstos, de maneira específica, para utilização nas etapas posteriores. Trata-se da aplicação do princípio da especialidade, que impede a ocorrência de bis in idem, intolerável na ordem constitucional brasileira.

4. O tratamento legal conferido ao tráfico de drogas traz, no entanto, peculiaridades a serem observadas nas condenações respectivas; a natureza desse crime de perigo abstrato, que tutela o bem jurídico saúde pública, fez com que o legislador elegeisse dois elementos específicos necessariamente presentes no quadro jurídico-probatório que cerca aquela prática delituosa, a saber, a natureza e a quantidade das drogas para utilização obrigatória na primeira fase da dosimetria.

5. Não há margem, na redação do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, para utilização de suposta discricionariedade judicial que redunde na transferência da análise desses elementos para etapas posteriores, já que erigidos ao status de circunstâncias judiciais preponderantes, sem natureza residual.

6. O tráfico privilegiado é instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual.

7. A utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura bis in idem, expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário n.

666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712).

8. A utilização supletiva desses elementos para afastamento do tráfico privilegiado somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa.

9. Na modulação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, podem ser utilizadas circunstâncias judiciais não preponderantes, previstas no art. 59 do Código Penal, desde que não utilizadas de maneira expressa na fixação da pena-base.

10. Recurso provido para restabelecimento da sentença. (REsp 1887511/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 01/07/2021)

O delito de tráfico de drogas é punido com pena de reclusão, de 5 a 15 anos, e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto e a de

detenção, em regime semiaberto ou aberto, conforme o montante aplicado (menor que 4 anos, maior que 4 anos e menor que 8 anos ou maior que 8 anos) e a presença ou não de reincidência e antecedentes (art. 33, caput e §2º, do CP, Súmulas 269 e 440 do STJ e Súmulas 718 e 719 do STF).

A pena de multa é calculada em dias-multa, sendo, no mínimo, de 10 e no máximo de 360 dias-multa (art. 49 do CP), segundo o critério trifásico previsto no art. 68 do CP.

O valor do dia-multa não pode ser inferior a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, devendo ser considerada a situação econômica do réu (art. 60 do CP).

Na primeira fase, quanto aos antecedentes, verifica-se que o acusado possui condenação transitada em julgado para a Defesa em 12/04/2019 (data do fato: 28/02/2016) (fls. 129/130).

Conforme o entendimento jurisprudencial, as condenações por fatos posteriores ao descrito na denúncia não caracterizam antecedentes e condenações antigas podem ser valoradas negativamente porque os antecedentes não se sujeitam ao prazo depurador de 5 anos aplicável à reincidência (art. 64, I, do CP)

A jurisprudência atual desta Corte, sedimentada no Enunciado de Súmula 444, veda às instâncias inferiores valorar negativamente a pena-base em função de inquéritos ou processos em curso, sem trânsito em julgado, em respeito ao princípio da presunção de não culpa. Ainda, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, não é possível considerar a condenação transitada em julgado, correspondente a fato posterior ao narrado na denúncia, para valorar negativamente antecedentes, conduta social ou personalidade do agente. Entrementes, plenamente viável que a condenação por fato anterior à infração penal em processo de dosimetria, mas com trânsito em julgado superveniente a ela, seja utilizada como circunstância judicial negativa. (HC 443.678/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 26/03/2019)

Nos termos da jurisprudência desta Corte, a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base. (HC 433.543/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018)

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA.

CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM

OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal). 3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. 4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal. (RE 593818, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-277 DIVULG 20-11-2020 PUBLIC 23-11-2020)

Assim, a condenação mencionada deve ser utilizada para caracterizar a reincidência, que é circunstância agravante, a ser valorada na segunda fase (Súmula 241 do STJ). Por sua vez, a natureza e quantidade de drogas encontradas apenas corroboram a caracterização do tráfico, não justificando a exasperação da pena-base.

Ainda de acordo com a jurisprudência, "Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente" (Resp 1794854/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em



23/06/2021, DJe 01/07/2021).

Diante disso, as demais circunstâncias judiciais (culpabilidade, entendida como grau de reprovabilidade do ato praticado; conduta social e personalidade do agente; motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como comportamento da vítima) não devem ser valoradas negativamente, pois inexistem peculiaridades fáticas aptas a justificarem a exasperação da pena-base.

Consequentemente, a pena deve partir do mínimo legal, ou seja, 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, relevante para a formação da condenação judicial (Súmula 545 do STJ). Presente também a agravante da reincidência, pelo antecedente mencionado. Logo, a reincidência deve ser compensada com a confissão, como prevalece na jurisprudência: 2. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a confissão do acusado, ainda que parcial, condicionada ou posteriormente retratada, enseja a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, desde que utilizada como fundamento para a condenação. (AgRg no HC 625.076/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é estável no sentido de que a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal independe se a confissão foi integral, parcial, qualificada, meramente voluntária, condicionada, extrajudicial ou posteriormente retratada, quando utilizada para fundamentar a condenação. (HC 480.489/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 03/04/2019)

A Terceira Seção desta Corte, no exame do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, em 10/4/2013, decidiu que, observadas as especificidades do caso concreto, "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência", uma vez que são igualmente preponderantes. (HC 605.603/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021) Consequentemente, a pena não se altera.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena.

Nesse sentido, a reincidência afasta a caracterização o tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06).

Logo, torno definitiva a pena em: 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Inexistindo razões em sentido contrário, fixo o dia-multa no mínimo legal, ou seja, um trigésimo do salário-mínimo vigente na época do fato, atualizado monetariamente até a data do pagamento (art. 49, §2º, do CP).

Pela reincidência, a pena privativa de liberdade deve ser cumprida em regime inicial fechado (art. 33, §2º, a, do Código Penal).

Deixo de considerar o tempo de prisão preventiva para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, por entender que tal avaliação compete ao juízo da execução criminal, haja vista que para a progressão de regime é necessária a presença da boa conduta carcerária (art. 112, §1º, da Lei 7.210/84), requisito subjetivo que, por isonomia, deve ser exigido de todos, sentenciados e presos provisórios (art. 387, §2º, do CPP).

O acusado não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nem à suspensão condicional da pena, uma vez que é reincidente e a pena é maior que 4 anos, de modo que a concessão dos benefícios não seria suficiente ou socialmente recomendável (arts. 44, 59 e 77 do CP).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar ENILDO OLIVEIRA DOS ANJOS à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Por não mais interessar ao processo, autorizo a destruição do entorpecente apreendido (art. 72 da Lei 11.343/06 e art. 524-A das NSCGJ). Comunique-se à autoridade policial responsável, preferencialmente por meio eletrônico (art. 524-A, §2º, das NSCGJ). Serve a presente como ofício.

Como efeito da condenação, declaro a perda dos bens e valores apreendidos (arts.

5º, LIV, e 243, parágrafo único, da Constituição e art. 91 do CP). Os bens poderão ser destinados à conservação e utilização, se houver interesse público, ou à alienação, enquanto o produto da arrematação e valores apreendidos deverão ser mantidos em depósito até o trânsito em julgado (arts. 61 a 63 da Lei 11.343/06). Comunique-se à autoridade policial responsável, preferencialmente por meio eletrônico. Serve a presente como ofício.

Custas pelo réu, observada a gratuidade de justiça.

O acusado responde ao processo preso preventivamente após ser surpreendido em flagrante e a necessidade de custódia cautelar permanece em virtude da gravidade concreta da conduta, devido à reincidência e apreensão de petrechos, contexto que evidencia que a prisão é necessária para evitar a reiteração da prática delitiva, mostrando-se ineficaz medida cautelar diversa, inclusive pela possibilidade de prática de tráfico em domicílio (arts. 282, §6º, e 312 do CPP).

Por tais motivos, recomende-se o acusado à prisão em que se encontra (art. 387, §2º, do CPP). Serve a presente como ofício.

Decorrido o prazo recursal, expeça-se certidão de honorários.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, expeçam-se os ofícios para as comunicações necessárias ao egrégio Tribunal Regional Eleitoral e IIRGD (art. 15, III, da Constituição e art. 398 das NSCGJ) e a guia de recolhimento definitiva (art. 467 a 474 das NSCGJ); bem como calcule-se a multa, intimando-se as partes para se manifestarem (arts. 479 a 483 das NSCGJ).

Expedida a guia, ela deverá ser encaminhada ao Juízo da Execução mediante lançamento da movimentação "processo findo", com a situação "suspensão" (art. 468, §3º, das NSCGJ), certificando-se nos autos.

Após, nada mais restando a deliberar, archive-se, fazendo-se as anotações necessárias no sistema informatizado (art. 184 das NSCGJ).

Saem os presentes intimados.

José Bonifacio, 05 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA